Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do	1.0024.17.131538-5/001	**Númeração**	1315385-
Relator:	Des.(a) Pedro Vergara		
Relator do Acordão:	Des.(a) Pedro Vergara		
Data do Julgamento:	01/10/2019		
Data da Publicação:	07/10/2019		

Ementa Oficial: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - NECESSIDADE - GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA NÃO COMPROVAS EM JUÍZO - TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER - REDUÇÃO DA PENA - VIABILIDADE - REPRIMENDA FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL - ALTERAÇÃO DO REGIME - INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO - APELANTE REINCIDENTE - ISENÇÃO DAS CUSTAS - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Necessária é a desclassificação da conduta para as sanções do artigo 155 do Código Penal eis que a grave ameaça ou a violência não foram comprovadas em juízo, havendo apenas testemunhas de ouvir dizer. 2. Reduz-se a pena corporal e de multa porquanto fixadas de forma desproporcional com as balizas judiciais do artigo 59 do Código Penal. 3. Mantém-se o regime fechado diante da pena e da reincidência do apelante. 4. Prejudicado se encontra o pedido de isenção das custas já que deferido pelo magistrado primevo. 05. Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.17.131538-5/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): PHILIPE AUGUSTO MARES - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO.

DES. PEDRO COELHO VERGARA

RELATOR.

DES. PEDRO COELHO VERGARA (RELATOR)

V O T O

I - DO RELATÓRIO - Cuida-se de AÇÃO PENAL PÚBLICA promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra PHILIPE AUGUSTO MARES como incurso nas sanções do artigo 157 § 2º inciso I do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 19 de Outubro de 2017 por volta das 08:53 horas no local conhecido por Avenida Abílio Machado nº 3980 Bairro Serrano na Comarca de Belo Horizonte o apelante mediante grave ameaça consistente em emprego de arma de fogo subtraiu para si 03 [três] maços de cigarros da marca San Marino, 14 [quatorze] embalagens de chocolate da marca Prestígio e a quantia de R$ 20,00 [vinte reais] pertencentes ao estabelecimento comercial Padaria Pão de Milão tudo conforme consta do anexo inquérito policial [f.01D-02D].

Recebida a denúncia o apelante foi citado, apresentando a defesa preliminar de f.79v [f.75 e 78].

As testemunhas arroladas foram ouvidas, interrogando-se o apelante, nada requerendo as partes em diligência [mídia de f. 98].

O Órgão Ministerial pede nas alegações finais a condenação nas sanções do artigo 157 do Código Penal, rogando a defesa a desclassificação para o delito de furto, o afastamento da majorante, a

fixação da pena no mínimo legal, a observância do regime semiaberto, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a isenção das custas [f.99-100v e 103-105].

Proferida a sentença o apelante foi condenado nas sanções do artigo 157 do Código Penal à pena de 04 [quatro] anos e 09 [nove] meses de reclusão e ao pagamento de 53 [cinquenta e três] dias-multa sobre 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época do fato no regime fechado [f.114-117v].

Inconformado com a decisão recorreu a defesa objetivando, a desclassificação para o delito de furto, a redução da pena, a alteração do regime e a isenção das custas, rogando o Parquet o parcial provimento do pleito, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso [f.133-137v, 138-140 e 147-150].

É o breve relato.

- VOTO -

II - Da admissibilidade - Conheço do recurso já que presentes estão os pressupostos para sua admissão.

III - Das preliminares - Inexiste na espécie qualquer nulidade tampouco causa de extinção da punibilidade.

IV - Do mérito - Cuida-se de delito de roubo cuja norma penal incriminadora se encontra insculpida no artigo 157 do Código Penal.

Resume-se a questão à análise da possibilidade de desclassificação para o delito de furto, de redução da pena, de alteração do regime e de isenção da custas.

Do pedido de desclassificação para o delito de furto - A defesa solicita a desclassificação do delito de roubo para as sanções do artigo 155 do Código Penal.

Razão lhe socorre.

O apelante confessou a subtração em juízo, negando, todavia, o emprego de ameaça, conforme se observa da mídia de f.98.

A vítima Cristiane Gomes Simões Martins dos Reis por sua vez narrou os fatos, alegando que o apelante a ameaçou no momento da prática delitiva, exibindo inclusive uma arma de fogo como se lê à f.05.

Esta, entretanto, apesar de devidamente intimada, não compareceu em juízo, sendo dispensada, não confirmando assim a dinâmica dos fatos, conforme se observa à f.91 e 97.

Este, portanto, é o conjunto probatório colhido na fase de inquérito que não foi ratificado em juízo, inexistindo ainda prova testemunhal direta que confirmasse a grave ameaça empregada pelo apelante no momento da prática delitiva.

Existe na fase judicial, portanto, somente prova testemunhal indireta sobre os fatos narrados pela vítima, o que não se encontra suficiente para fundamentar um édito condenatório nas sanções do artigo 157 do Código Penal.

Os policiais Adelmo Raposo Quintino e Mateus José Rodrigues Alves se limitaram a ratificar os depoimentos prestados na fase inquisitiva - 02 e 03 - que por sua vez se basearam no depoimento da vítima que não confirmou os fatos sob o crivo do contraditório [mídia de f.98].

Os policiais desta forma não presenciaram os fatos, estes apenas reproduziram o que a vítima narrou na fase extrajudicial, o que constitui prova demasiadamente indireta para a manutenção da condenação pela prática do delito de roubo.

O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

"PENAL - ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES - ELEMENTOS

INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO - PROVAS JUDICIALIZADAS FRÁGEIS E INDIRETAS - ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. A limitação moderada em relação aos elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, há muito acolhida na jurisprudência pátria, faz-se hoje expressamente prevista na legislação processual penal vigente diante das alterações introduzidas pela Lei nº 11.690/08, que deu nova redação ao art. 155 do CPP. Embora se deva dar crédito ao testemunho policial, o mesmo constitui prova demasiado indireta para uma condenação se o policial não presenciou os fatos e apenas ratificou a versão extrajudicial da vítima, a qual, por sua vez, não foi ouvida em juízo. É de se invocar a prevalência da dúvida se as provas judicializadas são frágeis e indiretas, devendo prevalecer, neste caso, a solução absolutória à luz do princípio do in dubio pro reo." [Apelação Criminal nº 1.0024.01.592278-4/001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez - TJMG - data da publicação 06/08/2010].

Saliente-se ainda que a arma supostamente utilizada pelo apelante para ameaçar a vítima no momento da prática delitiva, conforme narrado por esta na fase inquisitiva, sequer foi localizada apesar de o apelante ser seguido e abordado logo após a subtração.

Há, portanto, na fase judicial, meros indícios e elementos probatórios indiretos no sentido de que no momento do delito o apelante ameaçou a vítima, o que não constituem prova segura e estreme de dúvida para a manutenção do édito condenatório nos termos da sentença, devendo ser respeitado assim o que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal.

O ônus da prova cabe ao Ministério Público e se este não se desincumbiu de provar em juízo como os fatos ocorreram, que houve ameaça no momento da prática delitiva, a desclassificação para o delito de furto é medida que se impõe em observância ao princípio do in dúbio pro reo.

Desclassifico assim a conduta do apelante para as sanções do artigo 155 do Código Penal, passando à reestruturação da pena após a

análise do pedido defensivo de redução da pena.

Do pedido de redução da pena - A defesa pede ainda a redução da pena.

Razão lhe assiste em parte.

O magistrado primevo considerou desfavorável ao apelante os antecedentes, fixando a pena acima do mínimo legal - 04 [quatro] anos e 09 [nove] meses de reclusão -, que no meu entender se encontra exacerbada.

Este fixou ainda a pena de multa sem observar o critério trifásico, de forma desproporcional a pena corporal, o que também não se encontra acertado.

Contudo, fundamentou suas razões de decidir, respeitando o que dispõe o artigo 93 inciso IX da CR/88, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, mas, apenas em reestruturação das penas.

Necessária se faz, todavia, a reestruturação da pena eis que fixada de forma desproporcional com as balizas judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Os antecedentes realmente desfavorecem ao apelante, pois, há na CAC de f.111-111v mais de uma condenação apta a configurar a reincidência e esta baliza de forma negativa.

A regra matemática, por sua vez, observada para exasperar a pena, no meu entender, não merece prosperar, devendo ser analisada as circunstâncias de cada caso e, in casu, o aumento observado está exacerbado, o que impõe a redução da reprimenda.

Ante tais considerações passo a reestruturação da pena corporal e de multa:

- na primeira-fase; - considerando os antecedentes negativos, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal em 01 [um] ano e 03 [três] meses de reclusão e ao pagamento de 11 [onze] dias-multa;

- na segunda-fase; - presente a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência, compenso-as, nos termos da sentença fustigada, mantendo a pena inalterada;

- na terceira-fase; - inexistindo causa de aumento ou de redução da pena, fixo a reprimenda definitivamente em 01 [um] ano e 03 [três] meses de reclusão e ao pagamento de 11 [onze] dias-multa sobre 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente a época dos fatos, atualizando-se na forma da lei.

Do pedido de alteração do regime - A defesa requer ademais a alteração do regime.

Razão não lhe socorre.

Considerando a pena aplicada, os maus antecedentes e a reincidência do apelante, necessária se encontra a fixação do regime fechado ut artigo 33 § 2º alínea "a" do Código Penal nos termos da sentença fustigada que fundamentou devidamente o regime aplicado como se lê à f.117.

O apelante é reincidente específico na prática de crime contra o patrimônio e possuidor de maus antecedentes, o que impõe a fixação de um regime mais severo, conforme devidamente observado na sentença fustigada.

O fato de as balizas judiciais serem na maioria favorável e a pena abaixo de quatro anos não é suficiente para a fixação do regime mais brando, devendo ser levado em consideração que o apelante é useiro e vezeiro na prática de delito, em respeito ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade.

As súmulas 718 e 719 do STF se encontram, ainda, devidamente

respeitadas, pois, no presente caso, o regime de cumprimento de pena é mais severo que a pena aplicada em razão de motivação idônea, a reincidência e os antecedentes do acusado.

A observância da reincidência não configura ainda bis in idem, podendo tal questão subjetiva ser analisada e ponderada durante a fase da dosimetria da pena e do regime, sendo punidos mais severamente aqueles que querem reiterar na prática de ilícitos.

Mantenho assim o regime fechado, afastando-se o pleito defensivo.

Em consequência, extinguo a punibilidade do apelante pelo cumprimento da pena, considerando a reprimenda aplicada e a data da prisão em flagrante em 19 de Outubro de 2017.

Do pedido de isenção das custas - A defesa pede por fim a isenção do pagamento das custas processuais.

Apesar de já ter me manifestado no sentido de isentar os assistidos pela Defensoria Pública do pagamento das custas processuais, revi meu posicionamento.

O pagamento das custas é um dos efeitos da condenação, cabendo assim ser decidido pelo Juízo da Execução, momento que será analisada a real situação econômica e financeira do apelante.

Este é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS - INVIABILIDADE - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REANÁLISE - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE APENAS UMA VEZ NA DOSIMETRIA, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DO BIS IN IDEM - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - FRAÇÃO

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE - PLEITO DEISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO.

[...] Conforme estipula o artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação nas custas decorre de expressa previsão legal, devendo suposta impossibilidade de pagamento ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. [Apelação Criminal nº 1.0184.15.002209-5/001, Rel. Des. Wanderley Paiva - TJMG -, data da publicação 02/09/16].

Referido pedido se encontra, todavia, prejudicado já que deferido pelo magistrado primevo como se observa à f.117v.

Desclassifico assim a conduta do apelante para as sanções do artigo 155 do Código Penal e reduzo a pena, fixando-a 01 [um] ano e 03 [três] meses de reclusão e ao pagamento de 11 [onze] dias-multa sobre 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente a época dos fatos, atualizando-se na forma da lei, mantendo-se as demais cominações da sentença fustigada.

V - DO PROVIMENTO - Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, extinguindo em consequência a punibilidade pela prescrição.

Expeça-se alvará de soltura em favor de Philipe Augusto Mares se por al não estiver preso.

Proceda-se na forma do artigo 201 parágrafo 2º do Código de Processo Penal.

É como voto.

Custas isentas nos termos da decisão de f.117v.

DES. ADILSON LAMOUNIER (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. EDUARDO MACHADO - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO"